

刑法
No.355

H23-9

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】における甲の罪責に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい(ただし、事例において、公共の危険は発生したものとする。)

【事例】

甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。

【記述】

1. 火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合、同家屋に対する延焼罪が成立する。
2. 甲は、火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが、同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合、他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
3. 火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において、甲と乙が、同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため、放火することを共謀していたときは、他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
4. 火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において、現実には同家屋内に乙がいたのに、乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲が誤信していたときは、現住建造物等放火罪が成立する。
5. 甲は、火が家屋に燃え移ることを認識・認容していただけでなく、同家屋内で就寝中の乙が焼け死ぬことを認識・認容していた場合、現実には乙が焼死したときには、現住建造物等放火罪と殺人罪が成立し、後者は前者に吸収される。

No.355	放火罪の故意		正答率
H23-9	正解	2、4 (順不同)	60%

1 誤っている

111条1項によれば、延焼罪は、109条2項（自己所有非現住建造物等放火罪）又は110条2項の罪（自己所有建造物等以外放火罪）を犯し、よって108条（現住建造物等放火罪）又は109条1項（他人所有非現住建造物等放火罪）に規定する物に延焼させたときに成立する。本事例では、甲は乙所有の自動二輪車に放火している。これは他人所有建造物等以外放火罪（110条1項）にあたるが、109条2項又は110条2項の罪を犯したわけではないため、111条1項の罪は成立しない。また、111条2項によれば、延焼罪は110条2項の罪を犯し、よって110条1項に規定する物に延焼させたときにも成立する。本問の事例では、甲は他人所有建造物等以外放火罪（110条1項）を犯しているが、110条2項の罪を犯したわけではないため、111条2項の罪も成立しない。

2 正しい

本記述では、甲は乙が所有し単身で居住している家屋を炎上させているが、同家屋は空き家であって同家屋内には誰もいないものと甲が誤信している。このとき、甲は、主観的には他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）の故意で、客観的には他人所有現住建造物等放火罪（108条）に該当する行為を行っている。この場合、38条2項により、重い罪にあたる108条の罪は成立しない。では、甲に109条1項が成立するか、38条2項にはどの範囲で故意犯が成立するかにつき明文がないため問題となる。この場合、両罪の構成要件の重なり合う限度で、軽い罪の故意犯が成立すると解されている。本記述では、他人所有現住建造物等放火罪（108条）と他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）とは、少なくとも他人所有の建造物を放火するという点で構成要件的に重なり合うので、甲には軽い罪である他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立する。裁判例も、犯人が現住性及び現在性を認識せずに現住建造物を放火した事案において、他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）の成立を認めている（福岡高判昭38.12.20）。

3 誤っている

108条の「人」とは、犯人以外の者をさし、犯人には共犯者を含む（最判昭32.6.21、大判昭9.9.29）。本記述では、乙は共犯者にあたるため、108条の「人」にあたらない。よって、同家屋は、現住建造物等放火罪（108条）の客体にあらず、非現住建造物にあたる。次に、非現住建造物等放火罪（109条）の成否に関し、乙は共犯者であるため、同家屋は自己所有であるのが原則であるが、本記述では、同家屋に火災保険が掛けられているため、115条により、他人所有と扱われる。よって、甲・乙が同家屋を全焼させた行為について、他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立する。

4 正しい

故意とは、構成要件事実の認識・認容をいう。そして、現住建造物等放火罪における「現に人が住居に使用」（108条）とは、起臥寝食の場として日常利用されていることをいうが、昼夜間断なく人がその場所にいることを必要としない（大判大2.12.24）。本記述では、甲は、乙が外出中で同家屋内には誰もいないものと誤信しているものの、同家屋には乙が単身で居住し、起臥寝食の場として日常利用していることは認識・認容しており、甲に「現に人が住居に使用」の故意があるといえる。そして、108条の故意としては、現住性が現在性のいずれか一方の認識・認容があれば足りる。よって、甲には現在性の認識はないものの、現住建造物等放火罪の故意に欠けることはなく、現住建造物等放火罪が成立する。

5 誤っている

吸収関係とは、ある構成要件該当行為が他の構成要件該当行為を通常随伴する場合で、前者のみをもって後者が評価し尽くされている場合をいう。本記述では、甲の行為に現住建造物等放火罪と殺人罪が成立するが、放火罪と殺人罪はその罪質を異にし、前者のみをもって後者が評価し尽くされているとはいえないから、吸収関係にはない。甲の行為は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」る場合として、現住建造物等放火罪と殺人罪の観念的競合となる（54条1項前段）。